



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי: 2578/11

תחום החלטת המיסוי: הקצאת אופציות לעובדים

הנושא: אופציית רכש ומכר – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל עוסקת בניהול והשקעות בנכסים (להלן: "החברה").
2. החברה העניקה אופציות (להלן: "ההקצאה") לעובד החברה בתפקיד מנכ"ל (להלן: "העובד"), אשר איננו "בעל שליטה" בה טרם ההקצאה ושלא יהיה "בעל שליטה" בה עד מועד מימוש המניות, כתבי אופציה לא סחירים, במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה בעת מינוי העובד כמנכ"ל.
3. תוכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוח, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה על שם נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגין.
4. תוספת המימוש אשר נקבעה באופציות הייתה בהתאם לשווי השוק.
5. לאור היות האופציה זכות למניה בחברה שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא צפוי כי תרשמה למסחר בשנים הקרובות. ומאחר ובעלי המניות בחברה מחד מעוניינים להעניק לעובד אופציות למניות אשר תהינה ניתנות למימוש ומאידך אינם מעוניינים לאפשר לעובד למכור את מניות החברה לידי בעל מניות זר, החליט דירקטוריון החברה לכלול בתוכנית ההקצאה מתן אפשרות לעובד לחייב את החברה לרכוש ממנו את האופציות/המניות ובאופן הדדי, אפשרות לחברה לחייב את העובד למכור לה את האופציות/המניות (אופציית Put ו- Call), והכול לא לפני תום תקופת החסימה כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציית ה-PC").
6. בתוכנית ובכתב האופציה מכוחה ייקבע ויוגדר כדלקמן:
 - 6.1. אופציית PUT לעובד - החל ממועד המימוש של כתבי האופציה למניות של החברה, יהא העובד זכאי לדרוש מהחברה, על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי, לרכוש ממנו, בתוך שלושה חודשים ממועד הודעת המימוש, את כל מניות המימוש, והחברה מתחייבת בזאת להיענות לדרישת העובד (להלן: "אופציית ה-PUT"). היה ותמומש אופציית ה-PUT שהוקנתה לעובד, תשלום מחיר מימוש האופציות על ידי העובד, והתשלום של החברה עבור רכישת מניות המימוש מידי העובד, יתבצעו בד בבד.
 - 6.2. אופציית CALL לחברה - החל ממועד המימוש בפועל של כתבי האופציה למניות המימוש, תהא החברה זכאית לדרוש מהעובד, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובתוך שלושה חודשים ממועד הודעת המימוש, כי העובד ימכור לה את כל מניות המימוש, והעובד מתחייב בזאת להיענות לדרישת החברה (להלן: "אופציית ה-CALL").
 - 6.3. מחיר רכישת המניות במועד המימוש על-ידי החברה, על פי, אופציית ה-PC תקבע בהתאם לשווי השוק של החברה כפי שיחושב במועד השימוש באופציית ה-PC.

6.4. זכות סירוב ראשונה - בכל עת, החל ממועד המימוש בפועל של כתבי האופציה למניות המימוש וכל עוד לא מומשה אופציית ה-PC, העובד לא יהיה רשאי להעביר או למכור את מניות המימוש לצד שלישי, אלא לאחר שיעניק לחברה זכות סירוב ראשונה לרכוש את מניות המימוש, בהודעה בת שלושים יום מראש. (מובהר כי זכות זאת לא תחול במידה והחברה תהפוך לציבורית)

7. מובהר, כי אופציית ה-PC תחול אך ורק במקרה של פיטורים או התפטרות מוחלטת של העובד (לרבות סיום תקופת העסקתו שלא על דרך פיטורין או התפטרות), כגון מוות ונכות וכל עוד החברה לא הפכה לחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה. לעניין זה "מוחלטת" לרבות אי המשך התקשרות במסגרת נתינת שירותים או באמצעות צד קרוב, כמשמעות המונח בסעיף 88 לפקודה.

8. יובהר כי הזכויות העודפת כאמור אינו משנות את סיווג תוכנית האופציות החדשה לצרכים חשבונאיים, והתוכנית החדשה תמשיך להיות מסווגת כתוכנית הונית על פי FAS123R לפי כללי החשבונאות האמריקאיים ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ולא כתוכנית התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

הבקשה:

מבוקש כי לא יראו בהקצאת אופציית ה-Call ואופציית ה-Put ו/או במתן זכות סירוב ראשונה, כהפרה של אחד או יותר מהוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה. ויחולו על האופציות והמניות המוקצות מכוחן הוראות סעיף 102(ב)(2) לפקודה והכלים מכוחן. לרבות שיעורי המס החלים על הרווח.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בנסיבות אלו, ניתנה החלטה מיסוי, ביחס לאופציית ה-PC, ו/או זכות הסירוב הראשונה, כדלקמן:

1.1. ככלל, במידה ותוכנית האופציות תעמוד בתנאים שפורטו בסעיף 6 לעיל, לא יחשב מתן אופציית ה-PC ו/או מתן זכות סירוב ראשונה בתוכנית האופציות, כהפרת הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחן המתייחסים להקצאה באמצעות נאמן, כך שבמועד מימוש האופציות יחולו הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין.

1.2. יחד עם זאת, במקרה בו יבוצע מימוש האופציות באמצעות אופציית ה-PC, הרי שיחולו במימוש זה הוראות סעיף 102(ב) לפקודה, לפי העניין, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים להלן בלבד:

1.2.1. מימוש מניות העובד נבע בשל עזיבת העובד את החברה עקב פיטורים או התפטרות (לרבות סיום תקופת העסקתו שלא על דרך פיטורין או התפטרות),

1.2.2. יחסי העבודה, בין העובד לחברה הסתיימו באופן סופי ומוחלט, במישרין ו/או בעקיפין.

1.2.3. תמורת מכירת המניות על פי אופציית ה-PC חושבה בגובה שווי השוק, כמשמעות המונח בסעיף 85 לפקודה, של החברה ביום הודעת המימוש, כפי שייקבע על-ידי מומחה בלתי תלוי (להלן: "המעריך"), בקביעת שוויה של החברה על-ידי המעריך, יובאו בחשבון כל המרכיבים הכלכליים והעסקיים הרלוונטיים למועד ביצוע הערכת השווי, ובכלל אלו תזרים המזומנים של החברה והתחייבויותיה, יכולתה של החברה לתפקד כיחידה עצמית וכעסק חי והאיתנות הפיננסית של החברה.

2. למען הסר ספק יובהר כי מימוש האופציות באמצעות אופציית ה-PC, שלא בהתאם לאמור בסעיף 1.2 לעיל, תסווג מימוש אופציות שהוקצו שלא באמצעות נאמן, ויחולו עליה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, לפי העניין.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.